

1500991-45.2021.8.26.0363

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... em caso de condenação pelo crime de tráfico, pugnou pela pena mínima, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena em sua fração máxima e fixação de regime inicial aberto, além do afastamento da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas. Requereu, também, a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500991-45.2021.8.26.0363 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500991-45.2021.8.26.0363

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2221430/2021 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 19637968 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2006/21/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2221430 - DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PEIXOTO FERNANDES GOMES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

RAFAEL PEIXOTO FERNANDES GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c o artigo 40, III da Lei nº11.343/06, porque, segundo a denúncia e seu aditamento (fls. 133), nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, nas imediações da Praça dos Direitos Humanos e do Centro Dia do Idoso, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 21 porções de cocaína, droga ilícita causadora de dependência química. A denúncia foi recebida em 27 de agosto de 2021 (fls. 76/77). O réu foi citado

(fls. 144) e apresentou resposta à acusação (fls. 78/95).

Recebido o aditamento à denúncia para inclusão da causa de aumento de pena (fls. 193/194) e ratificado o recebimento da denúncia, realizou-se a audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu, interrogado ao final (fls. 242).

Em suas alegações finais orais, o Ministério Público, por meio de sua representante, requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da denúncia e de seu aditamento. Em relação à aplicação da pena, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da agravante da reincidência e a majoração da pena, nos termos do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. Opinou, ainda, pelo arbitramento do regime inicial fechado e se manifestou contrariamente à conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (mídia digital).

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do delito previsto no artigo 33 para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, em caso de condenação pelo crime de tráfico, pugnou pela pena mínima, bem como pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena em sua fração máxima e fixação de regime inicial aberto, além do afastamento da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei de Drogas. Requereu, também, a concessão do direito de recorrer em liberdade (fls. 236/240).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva e a autoria restaram comprovadas pela prova oral e pelas seguintes peças do inquérito policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01 e 04/13), boletim de ocorrência (fls. 02/03), auto de constatação preliminar de substância psicoativa (fls. 07/08), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 122/124).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado declarou que era usuário de drogas e que a droga apreendida nos autos destinava-se ao consumo pessoal. Declarou que costumava comprar quantidades maiores para não frequentar biqueiras e que possuía renda suficiente para a aquisição das drogas, por trabalhar como vendedor de pão de queijo e perceber mensalmente pensão no valor de R\$ 3.500,00. Respondeu, ao final, que costumava consumir de 30 a 40 cápsulas de cocaína por dia e que já havia passado por cinco internações (mídia digital).

A versão dos fatos apresentada pelo réu, entretanto, restou isolada nos autos.

O Guarda Municipal Eduardo Gabrelon relatou que, no dia dos fatos, estava em patrulhamento, quando um transeunte o informou de que um indivíduo estava comercializando drogas em local conhecido como ponto de tráfico. Prosseguiu, relatando que as características físicas e as vestimentas do acusado coincidiam com aquelas mencionadas pelo informante e que, além disso, ele esboçou um certo nervosismo, ao visualizar a viatura. Disse, ainda, que encontrou porções de droga em poder do réu e, também, em seu veículo. Finalizou, afirmando que o acusado já era conhecido nos meios policiais pela traficância (mídia digital).

Nesse mesmo sentido foi o depoimento do Guarda Municipal Ramon Rezende na fase policial, o qual foi ratificado por ele em juízo (mídia digital).

Importante salientar que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente quando não há nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou para prejudicar o acusado, como no caso em tela.

A orientação jurisprudencial é pacífica e torrencial no sentido de dar total valor aos depoimentos prestados por policiais militares ou guardas municipais. A título exemplificativo, temos o seguinte precedente jurisprudencial:

Nesse sentido, tem-se proclamado de forma reiterada na doutrina e na jurisprudência que a circunstância de ser a testemunha policial não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra. O STF pacificou entendimento nesse sentido ao decidir que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quanto prestados em juízo, sob garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato

de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Depreende-se das provas supracitadas que os guardas municipais lograram deter o acusado após receberem denúncia que informava com precisão as suas características físicas e as suas vestes e com ele encontraram vinte e uma porções de cocaína, embaladas em porções individuais, prontas para venda.

Assim, não há como se acolher a pretensão absolutória da defesa, pois a natureza e a quantidade da droga apreendida, a forma de sua embalagem e as circunstâncias em que se deu a prisão do réu permitem que se afirme com segurança que ele estava praticando o comércio ilícito de drogas.

Nesse sentido:

Tóxico. Tráfico. Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado. Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio. Desclassificação para uso inadmissível."(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273.

Oportuno lembrar que, por estar previsto em um tipo misto alternativo, o crime de tráfico ilegal de drogas (artigo 33 da Lei nº 11.343/06) pode ser configurado pela prática de qualquer um dos verbos descritos: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar. O acusado, por seu turno, limitou-se a afirmar que a droga destinava-se ao consumo próprio.

Contudo, não há que se falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, pois a quantidade de porções encontradas em poder do réu não se demonstra compatível com a posse para mero consumo. Ademais, apesar de o réu declarar que tinha uma renda mensal superior a R\$ 3.500,00, tal fato não basta para afastar a imputação de tráfico, haja vista que ele próprio declarou que costumava consumir cerca de quarenta porções de cocaína por dia, o que leva à conclusão de que a prática do tráfico financiava a sua dependência química.

A prova acusatória, portanto, demonstrou satisfatoriamente a responsabilidade penal do réu, de modo que não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, que não conseguiu demonstrar a veracidade de suas alegações, como já consignado anteriormente.

Por outro lado, não obstante a natureza objetiva da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06, essa não deve incidir no caso em tela, pois o crime de tráfico não estava sendo praticado nas dependências ou nas imediações dos locais descritos no aditamento da denúncia.

Preleciona Vicente Greco: "O termo 'imediações' não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a Lei procura coibir: as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem" (Lei de Drogas Anotada - Lei 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 145).

Analisando o levantamento do local segundo o critério desse eminente processualista, verifica-se claramente que a praça pública e o Centro Dia do Idoso não estão situados nas imediações dos locais do crime, pois distam, linearmente, mais de 280 metros de onde estava ocorrendo a traficância, sendo a distância real muito superior a 300 metros.

Nas imediações do local do crime há apenas igrejas, mas já está assentado na doutrina e na jurisprudência que templos religiosos não foram elencados no rol do inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06.

Nesse sentido:

EMENTA HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE.

ANALOGIA IN MALAM PARTEM. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. REGIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação da acusada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a sua absolvição, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 2. Uma vez que, no Direito Penal incriminador, não se admite a analogia in malam partem e porque a hipótese dos autos (tráfico de drogas cometido em local próximo a igrejas) não foi contemplada pelo legislador no rol das majorantes previstas no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, deve ser afastada a causa especial de aumento de pena em questão. 3. Não há como ser reconhecida a incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas aos acusados possuidores de maus antecedentes. 4. As peculiaridades do caso concreto (maus antecedentes, quantidade e natureza da droga, bem como circunstâncias em que praticado o delito) justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da reprimenda aplicada. 5. Ordem parcialmente concedida, para afastar a majorante prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzir a reprimenda da paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Diante da condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, imperioso o perdimento do veículo que estava sendo utilizado como instrumento para a prática do crime.

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime de tráfico ilegal de drogas e a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta. Verifico que ele possui maus antecedentes, em virtude de ostentar uma condenação definitiva que gera reincidência, porém essa será considerada como agravante da pena, para que não haja bis in idem (fls. 26/27). Nada há de relevante quanto às demais circunstâncias, pois a sua culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito foram aqueles próprios à espécie. Ademais, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. A quantidade e a natureza da droga apreendida tampouco autorizam a exasperação da pena, nos termos do o art. 42 da Lei 11.343/06, haja vista que o acusado foi detido com menos de 5g de cocaína.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,

Em razão da reincidência, gerada pela condenação definitiva no processo 0000240-44.2016.8.26.0546 da 2ª Vara Judicial de Mogi Mirim, cujo trânsito em julgado ocorreu em 20/08/2018 (fls. 26/27), aumento a pena de 1/6 (um sexto), para que perfaça 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Consigno, por fim, o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, por ser reincidente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra RAFAEL PEIXOTO FERNANDES GOMES, para condená-lo ao cumprimento de uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Apesar de reconhecida, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, a inconstitucionalidade dos artigos 33, § 4º, e 44 da Lei 11.343/06, no tocante à proibição de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade, bem como de conceder sursis, por não estarem preenchidos os requisitos legais e por entender que tal medida é insuficiente como forma de punição, principalmente em razão de sua

reincidência específica.

Com fulcro no § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90, diante da pena aplicada e da reincidência, fixo o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Tendo em vista que permanecem vigentes as condições que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, principalmente a necessidade de garantia da ordem pública pela periculosidade demonstrada por ele, deixo de lhe conceder o direito de apelar em liberdade.

Recomendem-no na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

Custas "ex lege".

P.I.C.

Mogi Mirim, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA